

1500784-70.2021.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Aponta que crimes anteriores de roubo envolvendo os celulares foram comprovados. Destaca ter sido confirmado pela prova oral que o réu estava em poder dos aparelhos celulares objeto do crime, e que ele ofereceu a vantagem indevida aos policiais. Salienta não haver evidência de que os policiais tinham interesse em incriminar o réu, pessoa que nem sequer conheciam. Afirma que a versão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: 4056-6600 - E-mail: diadema2cr@tjsp.jus.br

1500784-70.2021.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500784-70.2021.8.26.0161

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Amarildo Melo da Conceicao

Juíza de Direito: Dra. CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZÉBIO

Vistos.

AMARILDO MELO DA CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 23, foi denunciado como incurso no artigo 180, §1º, por duas vezes, e no artigo 333, ambos do Código Penal, porque, em data incerta, entre os dias 13 de janeiro de 2021 e 19 de janeiro de 2021, nesta cidade e comarca de Diadema, adquiriu e recebeu, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, dois telefones celulares da marca Xiaomi, avaliados em R\$ 2.000,00, e pertencentes às vítimas Nathan Alecsander Pança e Rosa Ileide da Silva, coisas que devia saber ser produtos de crime. Também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionados, ofereceu vantagem indevida para os policiais militares Ivan Rodrigues Lima e Robson Gomes de Freitas, funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício.

A denúncia foi recebida em 15/07/2021 (fls. 115).

O réu foi citado (fls. 130) e, às fls. 134, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 139), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento que se realizou no dia 01/12/2022 por meio telepresencial, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos

da denúncia, argumentando que estão provados os fatos ali narrados. Aponta que crimes anteriores de roubo envolvendo os celulares foram comprovados. Destaca ter sido confirmado pela prova oral que o réu estava em poder dos aparelhos celulares objeto do crime, e que ele ofereceu a vantagem indevida aos policiais. Salienta não haver evidência de que os policiais tinham interesse em incriminar o réu, pessoa que nem sequer conheciam. Afirma que a versão do acusado está isolada nos autos, e ele não indicou o nome ou outro elementos que pudessem identificar a pessoa que lhe entregou os celulares objeto do crime. Aponta que os próprios policiais lograram fazer a consulta do aparelho, de forma que a versão do acusado no sentido de que o aparelho estava bloqueado é inverossímil. Aduz que o réu já foi processado pelo mesmo crime. Aponta que as ordens de serviço apresentadas não o socorrem, pois ele se valeu da atividade comercial por ele desenvolvida para cometimento do crime. Quanto à dosimetria, para o crime de receptação, aponta a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois os dois celulares foram subtraídos em datas diversas. Na segunda etapa, anota existira circunstância agravante da dupla reincidência. Pede seja reconhecido o concurso material entre todos os crimes. Requer seja fixado regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do acervo probatório. Aponta que a versão da testemunha policial Ivan, em Juízo, encontra-se divergente daquela por ela apresentada em sede policial, pois na delegacia não disseram que o acusado havia afirmado que trabalhava consertando celulares. Ressalta que o réu exercia seu trabalho de forma precária, consertando aparelhos usados e, portanto, sem nota fiscal, e que o fato de ele estar na posse dos aparelhos não demonstra que ele tinha conhecimento da origem ilícita. Destaca que o réu negou a prática do crime e ter oferecido dinheiro aos policiais. Indagada, uma das testemunhas policiais apenas fez referência à legislação, afirmando que o oferecimento da vantagem indevida era suficiente para a consumação do delito, sem considerar a possibilidade de prisão de outras pessoas envolvidas no ilícito. Salienta, ainda, que os celulares já tinham sido apreendidos, então nem haveria como o acusado fazer ligação para que trouxessem o dinheiro. Subsidiariamente, em caso de condenação, pede a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 180, §3º do Código Penal, ante a ausência de dolo pelo acusado. Requer ainda a fixação da pena base no mínimo legal.

Após, os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado parcialmente procedente o pedido condenatório, afastando-se apenas o concurso material entre os delitos de receptação em prol do reconhecimento de crime único dessa espécie.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 11 e 14), autos de reconhecimento de objeto (fls. 17/18), boletins de ocorrência do crime anterior (roubo envolvendo as vítimas Rosa e Nathan respectivamente às fls. 31/33 e 34/37) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ouvido em Juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que retirou 05 aparelhos para consertar, e dois deles era de uma pessoa que lhe disse não estarem dando sinal. Então levou para um amigo checar o que havia de errado com os aparelhos, quando descobriu que poderiam ser produto de crime, pois os celulares estavam bloqueados; quando retornava para devolver os aparelhos ao cliente, acabou abordado pela polícia. Sabe que para bloquear o IMEI, é necessário entrar em contato com a operadora. Sobre o cliente que lhe entregou os dois aparelhos, afirma conhecê-lo apenas pelo nome de Vagner, e este deixou os aparelhos na casa dele, réu. Aponta que nos celulares havia o facebook dele, de forma que com acesso às informações

poderia ter sido feita investigação. Não sabe onde o cliente mora. Seu amigo, o qual acredita trabalhar com caminhões, não quis se apresentar na delegacia. Disse que os policiais o ameaçaram, não tinha dinheiro, e nega ter oferecido qualquer quantia. Não conhecia os policiais antes dos fatos, e achou estranha a abordagem deles, e ficou com a impressão de ter sido vítima de armação. Sobre as ordens de serviço, havia levado à delegacia posteriormente a pedido do delegado; narra que quando recebe aparelhos para consertar não emite nota fiscal, apenas ordem de serviço. Revela que, no momento da abordagem, os aparelhos estavam identificados por nome, e a ordem de serviço fazia posteriormente à entrega do aparelho. Trabalha com conserto de celulares há cerca de 10 anos, e antes tinha uma loja fixa. Conta que os clientes não costumam entregar a nota fiscal junto com os aparelhos para fazer o conserto, de forma que ele, acuado, deve confiar neles. Quando os celulares estão com a tela quebrada, o que é o caso com a maioria dos aparelhos, nem é possível fazer pesquisas sobre a existência de bloqueios. Esclarece que aparelhos com IMEI bloqueado, pelo que sabe, não têm condições de ser reutilizado. O celular que utilizava era o da marca Motorola, os demais eram para conserto. Tal negativa, entretanto, foi contrariada pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual.

Em depoimento bastante seguro, a testemunha Robson Gomes de Freitas, policial militar, disse que fez a abordagem do réu, o qual estava com vários celulares, alguns de origem ilícita, razão pela qual o conduziram ao distrito policial. Narra que, no momento da abordagem, o réu ofereceu a quantia de R\$ 3.000,00, (três mil reais) que seria trazida por uma mulher. Não se recorda de explicação dada pelo réu dada a respeito dos celulares. Conta que o réu estava numa motocicleta, e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. Não se recorda quais aparelhos foram encontrados, mas havia mais de um ou dois celulares, e havia um tablet, pelo que se recorda. Não se lembra de documentos relacionados à manutenção dos aparelhos. Não prenderam a pessoa que levaria o dinheiro, já que o mero ato de oferecer o dinheiro já se considera crime.

No mesmo sentido, a testemunha Ivan Rodrigues Lima, também policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento, quando viram o réu, o qual demonstrou incômodo ao notar a presença da viatura policial, circunstância que motivou a abordagem. Durante a abordagem, em busca pessoal encontraram alguns celulares com ele, cuja procedência o réu não soube esclarecer. Em pesquisa junto ao COPOM, após pesquisa com o IMEI dos aparelhos, foram apontados boletins de ocorrência, indicando serem os aparelhos fruto de subtração. Narra que então conduziram o acusado à delegacia, porém antes ele tentou oferecer dinheiro para que o liberassem; disse que se os policiais da equipe quisessem ele faria uma ligação e uma pessoa traria o dinheiro em espécie. Deram voz de prisão ao acusado e o apresentaram na delegacia. Ele estava com uma motocicleta, e, pelo que recorda, acredita que os aparelhos estavam na motocicleta. Nenhum documento foi encontrado, que justificasse a posse desses celulares. Conta que nenhuma outra pessoa foi presa. Afirma que quando estava tentando justificar a posse dos celulares, o réu teria dito que arrumava celulares ou algo assim, então pediram documentos e notas fiscais, mas ele não as possuía; ele então mudou o discurso, e passou a afirmar que os aparelhos eram de parentes dele, mas não conseguiu demonstrar esse fato. Confirmou ter afirmado em seu depoimento prestado na delegacia que o réu teria dito que consertava celulares.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Verifica-se, portanto, que, em algum momento durante o lapso temporal descrito na denúncia, o acusado, o qual trabalha com conserto de celulares, recebeu os dois aparelhos que tinham sido subtraídos das vítimas Nathan e Rosa, conforme se

depreende da leitura dos boletins de ocorrência de fls. 31/33 e 34/37 e dos autos de apreensão, exibição, entrega e avaliação de fls. 11 e 14. Posteriormente, no dia 19 de janeiro de 2021, no período da tarde, as testemunhas policiais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram em uma motocicleta o réu que, ao notar a presença dos policiais, demonstrou nervosismo, fato que motivou a abordagem policial. Feita a busca pessoal, localizaram no bolso da calça dele os bens objetos do crime. Durante a abordagem, o réu ainda ofereceu a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) aos policiais para que o liberassem, porém lhe foi dada foz de prisão, sendo ele em seguida conduzido para a delegacia.

É certo que no delito de receptação a aferição do dolo do agente e da ciência da origem criminosa é difícil. Isto porque, é praticamente impossível penetrar no íntimo do infrator e, via de regra, os crimes são cometidos na clandestinidade. Contudo, a aferição do elemento subjetivo deste tipo penal pode ser feita pela análise circunstanciada das peculiaridades de cada caso e do agente, contrastadas com máximas de experiência, inclusive pela dificuldade de obtenção de prova direta, que, excluindo situações especiais, somente poderia se dar por confissão.

E, no caso concreto, não se pode excluir o dolo do réu, posto ter sido ele surpreendido pelos policiais em posse os aparelhos celulares que haviam sido roubados poucos dias antes e, ao ser indagado, não soube informar o paradeiro ou o contato do cliente que os entregou para conserto. É de se notar ser a versão apresentada por ele em seu interrogatório judicial no mínimo estranha pois, segundo ela, o próprio réu, que atua na atividade comercial de conserto de aparelhos celulares há cerca de 10 (dez) anos, apenas teria tomado ciência da possibilidade de existirem problemas relacionados à origem dos celulares após pedir a ajuda de um amigo.

O acusado, por atuar na atividade comercial de conserto de aparelhos celulares há tanto tempo, tendo sido inclusive processado e condenado por crime da mesma espécie, certamente sabia, ou deveria saber da importância de se fazer a verificação, previamente ao recebimento dos celulares para conserto, da existência de bloqueios relacionados aos IMEIs dos aparelhos pelo site da Anatel, providência que estava a seu alcance, tanto que as testemunhas policiais lograram fazê-lo imediatamente, no momento da abordagem, com auxílio do COPOM, segundo o informado pelo policial Ivan em Juízo. E o réu jamais poderia aceitar receber aparelhos celulares cujos IMEIs, por qualquer razão, não pudessem ser checados, sob pena de restar caracterizado o dolo eventual.

Nesse passo, ressalto que o crime de receptação foi praticado pelo réu em sua forma qualificada, nos termos do artigo 180, §1º do Código Penal, posto ser incontroverso que ele recebeu os celulares objeto do crime para conserto, no exercício da atividade comercial por ele desempenhada, como dito. E o dispositivo legal mencionado contempla expressamente a hipótese de dolo eventual, incriminando a conduta daquele que recebe ou adquire "em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime". No mais, o fato de o acusado ter demonstrado incômodo e nervosismo previamente à abordagem, e de ter lhes oferecido dinheiro para que o liberassem, conforme dito pelas testemunhas, são indícios a reforçarem a conclusão segura de que o réu agiu com dolo ao receber os celulares.

Entretanto, não é o caso de se reconhecer o concurso material ou formal, mas crime único de receptação. Isto porque, embora os 02 (dois) celulares tenham sido apreendidos, não há prova cabal que tenham sido adquiridos/recebidos em momentos distintos, devendo prevalecer a presunção de que foram recebidos na mesma oportunidade.

De outro lado, de conformidade com a prova oral produzida em Juízo, o crime de corrupção ativa ficou bem caracterizado. Os policiais são considerados funcionários públicos, nos termos do quanto dispõe o artigo 327 do Código Penal, e o réu ofereceu a eles a quantia de R\$ 3.000,00 para que eles deixassem de praticar ato de ofício, próprio de suas atribuições funcionais, dentre as quais evidentemente se encontra a de manter a ordem pública e prender quem quer que se encontre em flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com o mera promessa ou

oferecimento da vantagem indevida, sendo dispensável para a aceitação pelo funcionário, ou que este deixe de praticar o ato de ofício tal como deseja o agente, o que, se ocorrer, acarretará a incidência da qualificadora prevista no artigo 333, parágrafo único do diploma repressivo.

Por fim, havendo pluralidade de crimes (receptação qualificada e corrupção ativa) de espécies diversas, com objetividades jurídicas distintas e perpetrados com desígnios autônomos, não constituindo um deles etapa ou meio de execução do outro, aplica-se o concurso material tal como pretendido pelo Ministério Público.

Portanto, havendo provas suficientes a demonstrar a existência de autoria e a materialidade da conduta, a condenação do réu nas penas dos crimes de receptação dolosa qualificada e de corrupção ativa é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

A) Dosimetria da pena aplicável pela prática da receptação qualificada.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus Antecedentes (fls. 142/145 e 152/155 – as condenações anteriores serão consideradas para fins de reincidência). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, observo tratar-se de réu duplamente reincidente (fls. 142/145 e 152/155 – autos 0000799-62.2015.8.26.0537 e 0017374-30.2016.8.26.0564). Não observo a existência de outras circunstâncias agravantes ou de circunstâncias atenuantes a incidirem no caso. Dessa forma, exaspero as penas em 1/5, para 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a figura do privilégio, com fulcro nos artigos 180, § 5º, cc. 155, § 2º, ambos do Código Penal, considerando que os objetos do crime são dois aparelhos celulares avaliados em R\$ 1.000,00 cada um (fls. 11 e 14), valor quase equivalente ao do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e portanto não pode ser considerado reduzido para fins de incidência do favor legal.

No mais, ausentes outras causas de diminuição ou de aumento, torno definitiva a pena nos patamares acima indicados, para os crimes de receptação.

B) Dosimetria da pena aplicável pela prática do crime de corrupção ativa.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus Antecedentes (fls. 142/145 e 152/155 – as condenações anteriores serão consideradas para fins de reincidência). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, observo tratar-se de réu duplamente reincidente (fls. 142/145 e 152/155 – autos 0000799-62.2015.8.26.0537 e 0017374-30.2016.8.26.0564). Presente a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'b' do diploma repressivo, posto ser evidente que o réu tentou subornar os policiais para assegurar a impunidade pela prática dos delitos de receptação e, quiçá, a vantagem auferida com sua prática. Não observo a existência de outras circunstâncias agravantes ou de circunstâncias atenuantes a incidirem no caso. Dessa forma, exaspero as penas em 1/4, para 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a incidirem, assim, as penas para o crime de corrupção ficam mantidas nos patamares já alcançados.

Por fim, aplico o concurso material entre os crimes de receptação e de corrupção, e faço a somatória das penas, obtendo-se o montante de 06 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, o único aplicável à luz do disposto no artigo 33 do Código Penal e tendo-se em consideração, a quantidade de pena aplicada e a dupla reincidência do acusado, mostrando-se o referido regime o mais indicado para repressão das infrações penais e prevenção da prática de novas condutas.

De outro lado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da dupla reincidência do acusado e também da quantidade de pena aplicada, de forma que tal medida encontra óbice no disposto no artigo 44, incisos I e II do Código Penal. Pelas mesmas razões, impossível a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu AMARILDO MELO DA CONCEIÇÃO à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 180, §1º e no artigo 333, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Como respondeu solto a este processo, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/03 e artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Quanto aos celulares que permanecem apreendidos nos autos, passados 90 (noventa) dias contados da data em que proferida esta decisão, e não havendo pedido de restituição, caso os bens estejam em boas condições de conservação e utilização, fica autorizada a doação para instituição beneficente, devendo, no tocante aos aparelhos, serem apagados os dados pessoais que possam gerar constrangimento e/ou danos à honra e a imagem da pessoa. Tratando-se de aparelhos ou objetos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

Sentença não proferida em audiência. Publique-se e intime-se as partes.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA